Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0841432-21.2021.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Sueli Menin
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Primeiramente, determino à Chefia de Cartório que cumpra imediatamente o tanto determinado no despacho de f. 182, procedendo com a retificação do pólo ativo, devendo dela constar o Espólio de Sueli Menin.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais* movida pelo **Espólio de Sueli Menin** em face de **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – CASSEMS**, todos já qualificados nos autos.

A autora, falecida no curso do processo, alega que, desde 01/08/2020, é beneficiária do plano de saúde requerido (na qualidade de dependente), tendo direito à assistência básica em saúde, o que compreende consultas, internações, cirurgias e tratamentos para diversas doenças.

Neste sentido, conta que foi diagnosticada com "*melanoma metastático estagio IV (CID C43)*", tipo mais grave de câncer de pele, sendo submetida a cirurgias e tratamentos de quimioterapia e imunoterapia, os quais não foram suficientes para interromper o avanço da doença.

Afirma que, diante da piora de seu quadro clínico, consultou um especialista da área (Dr. Marcelo Rocha de Souza Cruz – CRM 100479), o qual, no dia 18/11/2021, recomendou que a autora realizasse uma "*quimioterapia com o esquema paclitaxel 175mg/m² e carboplatina AUC 5, ambos no D1 a cada 21 dias*", sendo a prescrição ratificada pelo médico da ré Dr. Amauri F. Oliveira (CRM/MS 3931), o qual ainda pediu a realização do exame "*testa fundetion one cdx*".

Aduz, contudo, que a ré negou a realização do exame e procedimento quimioterápico prescritos pelos médicos, sob a alegação de que os medicamentos "paclitaxel e carboplatina" não possuem indicação para a patologia da requerente, sendo classificado como uso "off-label", e portanto, excluídos da cobertura do plano de saúde.

Defende que a conduta da ré é abusiva e que lhe causou danos morais.

Requer, assim:

- tramitação prioritária do feito, por ser a autora idosa e portadora de doença grave;

- benesses da justiça gratuita;

- concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e providencie que a autora seja imediatamente submetida a "*quimioterapia com o esquema paclitaxel 175mg/m² e carboplatina AUC 5, ambos no D1 a cada 21 dias*", e à realização do exame "*testa fundetion one cdx*";

- ao final, pede a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Às f. 89/97, foram deferidas as benesses da justiça gratuita e da tramitação prioritária do feito em favor da autora. Deferiu-se, parcialmente a tutela de urgência pleiteada, apenas para obrigar a ré a fornecer à requerente tratamento quimioterápico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

com os medicamentos paclitaxel e carboplatina. Quanto à tutela de urgência relativa à realização do exame "*testa fundetion one cdx*", o pleito foi indeferido, por ausência de prova da negativa da ré. Ao final, designou-se audiência de conciliação.

Termo de assentada às f. 114/115, no qual constou que as partes não se compuseram.

Citada, a ré apresentou contestação de f. 116/157, na qual defendeu, inicialmente, que é entidade de autogestão, de modo que não se submete ao CDC. Impugna a justiça gratuita concedida à autora, vez que esta não comprovou sua hipossuficiência econômica. No mérito, diz que os medicamentos requeridos pela autora não são indicados para a sua patologia (off-label) e são de alto custo, não podendo ser custeados pela ré. Salienta que a situação não enseja danos morais e pede a improcedência do pedido.

Réplica às f. 176/177.

À f. 179, comunicou-se o óbito da requerente, pedindo-se a sucessão processual por seu espólio, representado pelo inventariante Valdemar Menin (f. 180).

À f. 182, deferiu-se o pedido de sucessão processual do pólo ativo, que passou a ser identificado como "espólio de Sueli Menin". Ao final, intimou-se as partes para indicação das provas pretendidas.

As partes, às f. 187 e 188/189, pediram o julgamento antecipado da lide.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais* movida por **Espólio de Sueli Menin (*representado pelo inventariante Valdemar Menin - f. 180*)** em face de **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – CASSEMS**, todos já qualificados nos autos.

Diante da renúncia de mandato, promovida pelo causídico do espólio requerente (Dr. Fabrizio Tadeu Severo dos Santos), conforme pedido de f. 190/191, proceda o cartório com as respectivas anotações junto ao SAJ. Anote-se que a parte requerente continua sendo representada pelos advogados Dra. Laura Patrícia Daniel Palumbo Fernandes e Dr. Felipe Santullo, nos termos do substabelecimento de f. 186.

No mais, tenho que o feito admite o julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, já que, intimadas a indicarem provas, as partes pediram o julgamento antecipado da lide.

1 – Da Impugnação à Justiça Gratuita

Citada, a ré apresentou contestação de f. 116/157, na qual impugna a justiça gratuita concedida à autora, vez que esta não comprovou sua hipossuficiência econômica.

A preliminar deve ser afastada.

Pois bem. Como se sabe, qualquer pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98, do CPC), **sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consoante art. 99, §3º, do CPC.**

Na hipótese em apreço, a autora, em atendimento ao disposto no art.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

99, §3º, do CPC, apresentou declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada (f. 13), razão pela qual foi deferido o seu pedido de concessão de benesses da justiça gratuita.

Ademais, na hipótese, a autora demonstrou que, por meio da declaração de imposto de renda, que aufere renda anual de R$ 22.510,00 (ou seja, R$ 1.875,73 mensal), o que é suficiente para nos levar à conclusão que, de fato, não tem condições de custear as despesas do processo.

E ainda que a requerida alegue que a autora não faz jus à benesse, é certo que não demonstrou a veracidade de suas alegações, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, na medida que limitou-se a dizer que a requerente tinha condições de arcar com as custas processuais, sem apresentar qualquer documentação que evidenciasse sua afirmação.

Assim, ante a ausência de elementos probatórios que demonstrem que a autora possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, **mantenho as benesses da justiça gratuita à mesma e rejeito a preliminar.**

2 – Do Mérito

2.1 – Das regras aplicadas ao caso

Convém destacar que o E. STJ, através da Sumula 608, previu a inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

Neste sentido, é sabido que a ré atua na modalidade autogestão, razão pela qual, inaplicável do CDC ao presente caso.

Nesse sentido, confira-se ementa prolatada pelo E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO FECHADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TIPO AUTOGESTÃO (GEAP). RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. RECURSO ESPECIAL N. 1285483/PB. PACIENTE PORTADOR DE PRIAPISMO. NEGATIVA DE COBERTURA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO À RÉ CASSEMS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1285483/PB, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo". (...) (**TJMS**. Apelação Cível n. 0833349-60.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/06/2018, p: 29/06/2018).

2.2 – Do pedido de Obrigação de Fazer

Destaco, desde já, que embora tenha ocorrido o óbito da requerente durante o trâmite do processo, não há que se falar em óbice para análise do pedido de obrigação de fazer formulado na inicial, já que, com a concessão da tutela de urgência na inicial, é importante analisar se tal obrigação, de fato, poderia ser ou não imputada à ré.

Pois bem. Embora as partes tenham liberdade em contratar, inclusive com a fixação das regras que irão reger a relação jurídica estabelecida entre estas (art. 421, CC), tem-se também que as mesmas devem obedecer aos Princípios basilares que norteiam o negócio jurídico, dentre eles a Boa-fé Objetiva, prevista no art. 422, do Código Civil, para o fim de garantir o equilíbrio entre os contratantes e a garantia da segurança do "*pacta sunt servanda" ("os pactos devem ser cumpridos").* Dentre eles, cita-se a boa-fé objetiva das partes envolvidas, que encontra previsão no art. 422, do Código Civil.

> *"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."*

Ressalta-se que a boa-fé objetiva configura uma regra de comportamento que deve ser obedecida pelos contratantes, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, ou seja, é indispensável nesse tipo de avença, a confiança mútua, ou seja, a segurança de ambas as partes, no que tange ao cumprimento do pactuado. **E é sob esta ótica que os contratos devem ser analisados.**

Feitas tais considerações, vê-se que restou incontroverso nos autos que as partes mantém relação jurídica relacionada à contratação de plano de saúde ofertado pela requerida, o que, inclusive, se demonstrou pelo extrato de pagamento de f. 79/81 e carteira de beneficiário de f. 15.

Além disso, se apurou, consoante documento médico de f. 20 e 24, **devidamente assinados pelos médicos Oncologistas Dr. Marcelo Rocha de Souza Cruz (CRM 100479) e Dr. Amauri F. Oliveira - CRM 3931/MS**, que a autora, ao tempo do ajuizamento da ação, era portadora de câncer de pele (*"melanoma cutâneo metastático*"), sendo indicado o tratamento quimioterápico com esquema "paclitaxel 175mg/m² e carboplatina AUC 5", ambos no D1 a cada 21 dias, e também a realização do exame denominado "testa foundetion one cdx".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

1905303

São Paulo, quinta-feira, 18 de novembro de 2021
Para: Sueli Menin
Data de Nascimento: 15/05/1956
SAME: 1905303
Endereço: Praça São Marcos - casa - CEP: 79006210 - Guanandi - Campo Grande - MS

Relatório Médico

Avaliei a Sra. Sueli Menin, 65 anos, com diagnóstico de melanoma metastático (CID C43), com progressão de doença após imunoterapia com ipilimumabe e nivolumabe. Devido ao volume de doença hepática e em ossos, com paciente sintomática, recomendo quimioterapia com o esquema paclitaxel 175mg/m2 e carboplatina AUC 5, ambos no D1 a cada 21 dias.

Atenciosamente,

Dr. Marcelo Rocha de Sousa Cruz
CRM: 100479

Prescrevo para ***Sr(a). SUELI MENIN***

SOLICITO :

1- TESTA foundetionONE CDx

DIAGNOSTICO: MELANOMA CUTANEO METASTATICO CID C44.9

Campo Grande - MS, 22 de novembro de 2021.

Ocorre que a ré negou o tratamento quimioterápico mediante uso dos medicamentos paclitaxel e carboplatina, sob a justificativa de que tais substancias não tem indicação para a patologia da requerente (câncer de pele), nos termos do documento de f. 27 e conforme reconhecido em contestação.

Além disso, negou a realização do exame "testa foundetione cdx", argumentando que este não tinha cobertura junto ao plano de saúde, conforme documento de f. 28 e ausência de impugnação em contestação (art. 341 do CPC).

Contudo, há de se reconhecer que a negativa perpetrada pela ré se deu de maneira ilícita e abusiva, impondo-se a procedência do pedido de obrigação de fazer, consoante fundamentação a seguir exposta.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que **a operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, por configurar ingerência na ciência médica**. Eis

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

julgado recente nesse sentido:

> *"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.*
> *3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.*
> *4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.*
> *5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).*
> *6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).*
> ***7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.***
> *8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.*
> *9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

> *desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).*
> *10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. [...] (STJ, REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).*

Ou seja, não caberia à ré questionar o tratamento prescrito pelo médico que assiste a parte autora, negando-lhe cobertura a tratamento, pois não é o plano de saúde quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA.

Ademais, **é inequívoco nos autos que os medicamentos solicitados (paclitaxel e carboplatina) possuem registro na ANVISA, válidos até 01/12/2017 e 01/11/2027,** respectivamente, conforme informações extraídas do site daquela Agencia Reguladora, não havendo óbice para o custeio pela ré, especialmente porque o plano de saúde em questão cobre o tratamento contra câncer, fato incontroverso nos autos:

Área

1 - MEDICAMENTOS

Registro

155370004

Produto

PACLITAXEL

Classe Terapêutica

ANTINEOPLASICO

Autorização

1055377

Processo

25351.310802/2006-70

Validade/Situação

01/12/2027 Publicado deferimento

» conforme visto em 26/03/2023
» consultar diretamente na anvisa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

Registro	Produto	Tipo	Detentor	Origem	Validade
15557300470026	CARBOPLATINA (001)	MEDICAMENTOS	TEVA FARMACÊUTICA LTDA.		01/08/2023
155370003	CARBOPLATINA	MEDICAMENTOS	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED - PLOT Nº 457 & 458, VILLAGE MATODA BAVLA ROAD AND PLOT N° 191/218P, VILLAGE CHACHARWADI, TAL ? SANAND, VILL: MATODA & CHACHARWADI-382 210, DIST: AHMEDA...	01/11/2027

Nota-se ainda que os medicamentos em questão, ao contrário do que alega a ré, são direcionados para o tratamento de câncer (agente antineoplásico), de modo que não havia justo motivo para a recusa perpetrada pela ré.

E ainda que o medicamento fosse considerado off-label, ou seja, fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA, tem-se que tal fato, por si só, não isenta a ré de promover a cobertura do tratamento à autora, vez que é possível que o medicamento seja utilizado para outros tratamentos, consoante informações do próprio site da Anvisa:

> ***"Quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela.*** *Outras indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, submetidas à Anvisa quando terminados os estudos, poderão vir ser aprovadas e passar a constar da bula. Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial podem, por exemplo, ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou para uma outra doença, assim como o uso pode se tornar mais restrito do que inicialmente se aprovou.(www.anvisa.gov.br)"*

Também convém salientar que tal entendimento não é contrário à legislação, vez que o caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica, o que não é o caso dos autos, vez que o remédio, conforme já destacado nos autos e conforme informações do proprio sitio da ANVISA, tem sua comercialização autorizada pela Agencia Sanitária.

Ademais, no caso em apreço, a ré sequer comprovou nos autos que o medicamento não seria útil para a patologia da autora, vez que sequer produziu provas neste sentido, deixando de formular pedido específico de produção de prova pericial apto a comprovar suas alegações de ineficácia do tratamento para a doença da parte autora, de modo que resta evidente o ilícito praticado pela mesma.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

O E. STJ, inclusive, já manifestou a respeito da abusividade dos planos de saúde em negar medicamento prescrito por médico especialista, ainda que Off-label, conforme Informativo 632/2018:

> ***"Planos de saúde. Negativa de fornecimento de medicação. Tratamento experimental. Uso fora da bula (off-label). Ingerência da operadora na atividade médica. Impossibilidade.***
>
> ***A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).***
>
> *O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). A Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). Por sua vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa n. 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que é considerado tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Quanto ao ponto, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que "não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)", a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Nesse sentido, a doutrina afirma que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 não abrange o uso off-label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera regulamentação do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998". O caráter experimental a que faz referência este inciso diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. Assim, a ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei n. 9.656/98, constitui ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC)."*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

A negativa do exame "*testa fundetion one cdx*" também não se justifica, já que, como dito, foi prescrito pelo médico da requerente (f. 24), não podendo a ré se recusar a faze-lo, ainda mais quando necessário para o tratamento do câncer, doença esta coberta pelo plano de saúde.

Por tais razões, a procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe, ratificando-se a tutela de urgência deferida nos autos.

3 – Dos Danos Morais

A Constituição Federal de 1988, ao fixar os direitos e garantias fundamentais, instituiu o direito à indenização por danos morais em seu art. 5º, incisos V e X.

Regulamentando tal direito, estabelece o artigo 186 do Código Civil que: "*Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*".

Em complemento, o art. 927 do Código Civil prescreve que: "*Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.*"

Desse modo, conjugando tais dispositivos, aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repara-lo. Entretanto, é certo que para vislumbrar tal responsabilidade é imprescindível a coexistência de três elementos fundamentais, quais sejam, o dano sofrido pela vítima, a conduta ofensiva praticada pelo agente e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada.

Compulsando a exordial, verifica-se que a autora pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por esta, sem justo motivo, ter-lhe negado tratamento médico prescrito por seu médico.

O pedido, neste particular, merece procedência, porquanto, em que pesem os argumentos da ré, é certo que o Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que, nos casos de negativa de cobertura de plano de saúde ou de seguro saúde, o dano moral é *in re ipsa*, mesmo sendo inadimplemento contratual.

Eis julgado nesse sentido:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.*
> *1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).
[...]
3. Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira os interesses jurídicos lesados (direito à vida e direito à saúde), tenho por razoável que a condenação deve ter como valor básico R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não destoando da proporcionalidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.
4. No que tange à segunda fase do método bifásico, para a fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a) trata-se de caso envolvendo consumidor hipossuficiente litigando contra sociedade empresária de grande porte; b) o ato ilícito praticado pela ora recorrida e que deu ensejo aos danos morais suportados pela recorrente relaciona-se à graves problemas de saúde decorrentes de acidente automobilístico, demandando a recorrente de tratamento fonoaudiólogo de urgência para a recuperação da capacidade de mastigação e deglutição; c) a recusa à cobertura das despesas relacionadas às sessões de fonoaudiologia inviabilizaria o próprio tratamento médico, impedindo, a rigor, a utilização de meio hábil à cura e inviabilizando a própria concretização do objeto do contrato.
5. Indenização definitiva fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)".

Nessa mesma linha caminha a jurisprudência do E. TJMS:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder pela omissão ao cumprimento de obrigações contratuais estabelecidas em favor dos beneficiários. II − Nos contratos de plano de saúde quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente, independente da incidência das normas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. O Rol de procedimentos médicos cobertos previsto pela ANS é exemplificativo. III - Na negativa de cobertura de procedimento médico o dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica do beneficiário. Precedentes do STJ. IV - O valor estabelecido a título de dano moral deve guardar pertinência com as peculiaridades do caso concreto e estar em consonância com os casos semelhantes já julgados por este Tribunal. Na espécie, mantém-se o valor da indenização por danos morais. V- Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMS. Apelação n. 0819986-06.2014.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 20/05/2019, p: 21/05/2019)".

No caso em comento, a autora sofria de doença grave (câncer de pelo), sendo necessário o uso dos medicamentos paclitaxel e carboplatina (para uso na quimioterapia) e também a realização do exame "TESTA fundetionONE CDX", para continuidade do seu tratamento médico.

Diante da gravidade da patologia acometida pela autora, com o notório sofrimento que a acompanha, tem-se que o obstáculo inescusável colocado pela requerida para o seu tratamento configura, indubitavelmente, danos aos seus direitos de personalidade, o que independe de qualquer prova específica.

Assim, caracterizada a conduta ilícita da requerida e verificado o seu dever de reparar os danos morais causados à requerente por tal fato, passa-se a analisar a questão dos danos propriamente ditos.

Em relação ao valor da indenização, é cediço que a fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica a valoração da proporcionalidade do quantum e a capacidade econômica do sucumbente.

Dessa forma, observando os precedentes judiciais e examinando as peculiaridades do caso em tela, com a atenção voltada à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, entende-se como suficiente o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Referido valor deverá ser corrigido pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, por tratar-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais, para o fim de:

A) reconhecer que era dever da ré, durante a vigência do plano de saúde, autorizar e providenciar à requerente, o tratamento denominado "*quimioterapia com o esquema paclitaxel 175mg/m² e carboplatina AUC 5, ambos no D1 a cada 21 dias*", e à realização do exame "*testa fundetion one cdx*", restando ratificada a tutela de urgência deferida nos autos;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

B) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** o qual deverá ser corrigido pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, juros de mora são devidos a partir da citação.

Ante a sucumbência, condena a ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora, os quais fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 27/03/2023 às 18:22 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841432-21.2021.8.12.0001 e código BxlM0ArO.